

1506840-55.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... período da tarde, visando a combater o tráfico de entorpecentes, após receberem denúncia de que um rapaz negro, trajando abrigo preto com detalhes brancos e vermelho (na blusa e na calça), estava praticando o tráfico de drogas no cruzamento da Rua Lúcia Raspante com a Rua João Soares Rosa, dirigiram-se ao local, juntamente com outros policiais. As testemunhas conduziam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506840-55.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 26 de abril de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506840-55.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001416

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON ANTONIO DAVID

Vistos.

DENILSON ANTONIO DAVID (RG: 57.119.671, filho de Donizete Antonio David e Maria de Lourdes Neres Ferreira) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 61, II, "j" do Código Penal, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 18h30, no cruzamento da Rua Lúcia Raspante com a Rua João Soares Rosa, Jardim Edison da Silva Lima, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de disseminação, sem autorização legal e regulamentar, 3 (três) porções contendo 0,15g de crack, 8 (oito) porções contendo 3,63g de cocaína e 3 (três) porções, sendo 2 (duas) individualizadas e 1 (uma) a granel, contendo 60,35g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, que contém tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 94/96), o réu foi citado (fls. 109) e apresentou defesa preliminar (fls. 119/129).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o acusado,

interrogado ao final.

Alegações ministeriais apresentadas em audiência, conforme termo retro. Memoriais defensivos constantes de fls. 181/194.

É o relatório. Fundamento e decidido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 14/17), laudo de constatação (fls. 19/21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 75/80) e pela prova oral colhida.

Os policiais civis Wellington e Fábio declararam, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, no período da tarde, visando a combater o tráfico de entorpecentes, após receberem denúncia de que um rapaz negro, trajando abrigo preto com detalhes brancos e vermelho (na blusa e na calça), estava praticando o tráfico de drogas no cruzamento da Rua Lúcia Raspante com a Rua João Soares Rosa, dirigiram-se ao local, juntamente com outros policiais. As testemunhas conduziam viatura descaracterizada e estacionaram nas proximidades, observando, pouco tempo depois, o acusado (que tinha as características mencionadas na denúncia) efetivar a venda a dois usuários que ali chegaram a pé. Asseveraram que o réu atendeu os clientes e, em seguida, foi até um terreno existente em frente a um bar, do outro lado da rua, pegou a droga e a entregou aos usuários. Após, permaneceu em frente ao estabelecimento mencionado. Certos da prática do crime de tráfico, os investigadores abordaram o acusado, apreendendo, em seu poder, R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro e 3 (três) pinos de cor rosa com crack, que estavam sob sua cueca. Em diligências no terreno em que o réu foi visto pegando droga, localizaram no interior de um saco plástico utilizado para embalar arroz, com o logotipo "SAFRA SUL", 8 (oito) pinos de cor azul com cocaína, e ainda um "tijolinho" e duas porções de maconha, a primeira não embalada, e as duas últimas envoltas em plástico transparente. Em juízo, corroboraram os relatos anteriores, acrescentando que o acusado não era, por eles, conhecido. Ainda, afirmaram que o bar no qual o réu se encontrava no momento da abordagem já era conhecido como ponto de venda de drogas. O acusado, por sua vez, na delegacia, alegou que havia trabalhado naquele dia como servente de pedreiro, recebendo R\$ 50,00 (cinquenta reais) pelo serviço, todavia não soube informar o endereço da obra em que trabalhou, nem indicar o nome do pedreiro responsável. Após o término do trabalho, passou em sua casa para trocar de roupa e dirigiu-se ao bar em que foi flagrado pelos investigadores. Relatou ter consumido pinga e cerveja no referido bar (gastando R\$ 15,00 - quinze reais) e, depois, foi até a biqueira existente nas proximidades e adquiriu 3 (três) pinos de crack por R\$ 15,00 (quinze reais). Ademais, negou que estivesse no local praticando o tráfico, desconhecendo a quem pertenceria a droga localizada no terreno. Quanto ao dinheiro, disse ser fruto do trabalho. Em seu interrogatório judicial, ratificou a versão anterior, acrescentando ser usuário de drogas há cerca de 3 (três) anos. Ainda, afirmou que os policiais o devem ter confundido com outra pessoa (salientando que havia outros indivíduos no bar), destacando que não os conhecia e nada tem contra eles.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal

Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, no período da tarde, visando ao combate do tráfico de entorpecentes no cruzamento da Rua Lúcia Raspante com a Rua João Soares Rosa, Jardim Edison da Silva Lima, após denúncia de que indivíduo negro trajando abrigo de cor preta com detalhes em branco e vermelho estaria praticando o tráfico de drogas, dirigiram-se até o local e, de pronto, visualizaram o acusado, que tinha exatamente as características informadas na denúncia, inclusive trajando roupa das mesmas cores das indicadas, sendo certo que se mantiveram estacionados nas proximidades em viatura descaracterizada. Em pouco tempo de observação, visualizaram o acusado vendendo drogas a dois transeuntes que ali passaram, verificando que os entorpecentes estavam ocultos em um terreno baldio existente em frente de um bar (já conhecido como ponto de venda de drogas). Certos da prática de delito, os investigadores procederam a abordagem, apreendendo na posse do acusado dinheiro e drogas (R\$ 20,00 - vinte reais, e 3 - três - pinos de cor rosa com crack) dentro da cueca de DENILSON. Ainda, no terreno em que visto buscando as drogas antes de entregar aos usuários, os policiais localizaram, no interior de um saco plástico utilizado para embalar arroz, com o logotipo "SAFRA SUL", 8 (oito) pinos de cor azul com cocaína e ainda um "tijolinho" e duas porções de maconha, a primeira não embalada e as duas últimas envoltas em plástico transparente.

De se notar que não convence a narrativa apresentada pelo acusado de que o dinheiro localizado consigo advinha de seu trabalho como pedreiro, eis que sequer indicou o nome de seu suposto chefe, bem como não soube dizer o endereço da obra. Ainda, os investigadores foram categóricos ao afirmarem que viram o acusado praticando ato típico de venda a dois usuários que passaram a pé, visualizando, outrossim, o local em que a droga era escondida (terreno baldio próximo ao bar em que flagrado o réu). Portanto, não há razões para se duvidar do relato dos investigadores, que não eram conhecidos pelo réu, ou seja, não há qualquer indicação de inimizade que os faria incriminar falsamente suspeito.

Outrossim, a tese de que seria mero usuário e não comercializaria drogas restou refutada pela prova dos autos. Com efeito, sequer ficou comprovado o exercício de atividade lícita por ele, ressaltando-se que improvável que, de fato, laborasse como servente de pedreiro (o que poderia ter sido comprovado documentalmente ou mesmo por simples declaração do suposto "patrão").

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado.

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (3 - três - porções contendo 0,15g de crack; 8 - oito - porções contendo 3,63g de cocaína; e 3 - três - porções, sendo 2 (duas) individualizadas e 1 (uma) a granel, contendo

60,35g de Cannabis Sativa L), o alto poder vulnerante de parte das drogas (crack e cocaína), além da forma de embalo (parte já prontas para entrega a consumo de terceiro e parte a embalar) e as circunstâncias da prisão (que se deu em local conhecido pela venda de entorpecentes após o réu ser visto pelos investigadores efetivamente praticando atos típicos de venda a dois usuários), revelam que se trata, o acusado, de traficante.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante de parte das drogas; acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro; local já conhecido como ponto de venda de drogas), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício. O que se quer dizer é que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada com o réu indicam a prática profissional do crime em questão.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante de parte delas (crack e cocaína), autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020:

"Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos".

Assim, majoro a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No terceiro estágio, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Primeiro, porque as circunstâncias judiciais assim autorizam. Depois, é

certo que o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de quaisquer benefícios ou a fixação de cumprimento inicial de pena em regime mais brando. Ademais, de se levar em conta a gravidade da conduta praticada. Neste sentido: “Caráter hediondo do delito, daí a correta fixação do regime fechado e a negativa da substituição da corporal por restritivas de direitos, até mesmo em razão da quantidade da pena.” (Apelação nº 0013049-83.2015.8.26.0196, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar DENILSON ANTONIO DAVID, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, do valor apreendido (R\$ 20,00 - vinte reais), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro (fls. 12).

Providencie-se o necessário para o cumprimento desta decisão e da pena.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Marília, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA